

<입문-제7장 행정의 실효성 확보수단.제1절 행정행위의 실효성 확보수단>

I. 행정상 실효성 확보수단의 의의

- 행정상 실효성 확보수단이란 행정법상의 의무를 이행하지 않거나 위반하는 경우, 행정주체가 그 의무의 이행을 확보하거나 의무 위반에 제재를 가함으로써, 행정목적의 실현하기 위해 사용하는 모든 공법적 수단을 말한다. 이는 행정의 실효성을 담보하고 법치 행정을 실현하는 데 필수적인 요소이다. 이러한 수단은 국민의 권리·자유를 침해할 우려가 크므로, 반드시 법률의 근거에 의해서만 발동되어야 한다.(법률유보의 원칙)

II. 전통적 행정강제수단

- 전통적인 실효성 확보수단은 주로 의무의 이행을 강제하거나 의무 위반에 대한 벌칙을 가하는 방식으로 이루어진다.

1. 행정강제

- 행정강제란 행정법상 의무의 불이행이 있을 때, 행정청이 장래에 향하여 의무 이행을 확보하기 위하여 가하는 강제 수단을 말한다.

(1) 대집행

- 대집행은 의무자가 행정법상 대체적 작위 의무를 이행하지 않을 때, 행정청이 스스로 의무자가 해야 할 행위를 대신 행하고 그 비용을 의무자로부터 징수하는 수단이다. 행정대집행법에 근거하며, 계고, 통지, 대집행 실행, 비용 징수의 4단계 절차를 거치는 것이 원칙이다. 계고는 취소소송의 대상인 처분으로 인정된다는 점이 중요하다.

(2) 직접강제

- 직접강제는 행정법상 의무의 불이행이 있을 때, 행정청이 의무자의 신체 또는 재산에 직접적인 힘을 가하여 의무 이행을 실현하는 수단이다. 이는 국민의 기본권에 대한 침해가 매우 크기 때문에 법적 근거가 엄격하게 요구되며, 최후의 수단으로 이용된다.

(3) 강제징수

- 강제징수는 공법상의 금전 급부 의무(조세, 과태료)를 불이행할 때, 행정청이 의무자의 재산에 실력을 행사하여 의무를 이행시키는 수단이다. 국제징수법 등에 근거하며, 독촉, 압류, 매각, 청산의 절차를 거친다. 독촉은 취소소송의 대상인 처분으로 인정된다.

(4) 즉시강제

- 즉시강제는 급박한 상황에서 의무를 명할 시간적 여유가 없을 때, 또는 의무를 명하는 것만으로는 목적 달성이 곤란할 때, 의무를 부과함이 없이 행정청이 직접 국민의 신체나 재산에 실력을 행사하여 행정목적의 즉시 실현하는 수단이다. 예를 들어 전염병 환자의 강제 격리, 화재 진압 등이 있으며, 이는 사후에 의무 부과를 대체하는 것이 아니며, 행정 조사와 구별된다.

2. 행정벌

- 행정벌이란 과거의 의무 위반 행위에 대하여 제재를 가하여 일반 예방적 효과를 도모하는 수단이다. 의무 이행 확보가 아닌 제재가 목적이므로, 행정강제와는 성격이 다르다.

(1) 행정형벌

- 행정형벌은 행정법상 의무 위반 행위에 대하여 형법이 정하는 바에 따라 징역, 금고, 벌금 등 형사 처벌을 가하는 것이다. 이는 행정청이 아닌 사법부(법원)의 재판을 통해 부과된다.

(2) 행정질서벌

- 행정질서벌은 행정법상 의무 위반에 대하여 비교적 경미한 처벌인 과태료를 부과하는 것을 말한다. 이는 원칙적으로 행정청이 부과하며, 과태료 부과 처분에 불복하면 비송사건절차법에 따라 법원에서 심판한다.

III. 새로운 행정강제수단

- 행정의 복잡화 및 전통적 수단의 한계(특히 비대체적 작위 의무나 부작위 의무 위반에 대한 미흡성)로 인해 보다 유연하고 실효적인 새로운 수단들이 등장하였다.

1. 등장 배경

(1) 비대체적 의무 증가

- 전문화된 현대 행정에서 단순한 대체적 작위 의무보다 행위자 본인만이 이행할 수 있는 비대체적 작위 의무나 부작위 의무가 증가하였다.

(2) 국민의 권리 보호 강화

- 직접강제와 같은 강력한 수단은 국민의 기본권을 과도하게 침해하므로, 이를 대체할 간접적 강제 수단의 필요성이 대두되었다.

(3) 행정 효율성

- 복잡한 행정 영역에서 행정주체가 직접강제하는 것보다 간접적인 제재를 통해 자발적 이행을 유도하는 것이 효율적이다.

2. 금전적 제재수단

(1) 이행강제금

- 이행강제금은 비대체적 작위 의무 또는 부작위 의무의 불이행 시, 그 의무를 이행할 때까지 반복적으로 금전적 부담을 부과하여 의무자에게 심리적 압박을 가함으로써 간접적으로 의무 이행을 강제하는 수단이다. 건축법상 시정 명령 불이행 시 부과될 수 있다. 이는 처분으로서 항고소송의 대상이 된다.

(2) 과징금

- 과징금은 행정법상 의무를 위반하여 경제적 이익을 얻었을 때, 그 위반 이익을 박탈하고 동시에 제재를 가하는 수단이다. 주로 시장 경제 질서와 관련된 법규 위반에 부과되며, 취소소송의 대상이 된다.

3. 비금전적 제재수단

(1) 공표

- 공표는 의무 위반 사실을 일반에게 공개하여 의무자에게 명예적 불이익을 줌으로써 의무 이행을 간접적으로 압박하는 수단이다. 위반 사실의 공표는 국민의 명예권 등 인권권 침해 우려가 크므로 법적 근거가 반드시 필요하며, 처분성이 인정될 수 있다.

(2) 과태료(행정질서벌)

- 과태료는 전통적 수단으로 분류되기도 하지만, 그 성격상 새로운 제재 수단으로 보는 경향도 있다.

(3) 영업 정지 등 각종 제재 처분

- 법령 위반에 따른 영업 정지, 취소 등은 전통적인 명령적 행정행위(하명)의 한 형태이지만, 실질적으로는 의무 위반에 대한 가장 강력한 제재 수단으로서의 역할을 한다.

IV. 실효성 확보수단 체계

- 행정상 실효성 확보수단은 그 목적과 성격에 따라 다음과 같이 체계화될 수 있다.

1. 의무 이행 확보 수단 (강제)

- 장래의 의무 이행을 목적으로 한다.

(1) 직접적 강제

- 대집행, 직접강제, 강제징수, 즉시강제 등

(2) 간접적 강제

- 이행강제금(집행벌) 등

2. 과거 위반에 대한 제재 수단 (벌칙)

- 과거의 의무 위반에 대한 응징을 목적으로 한다.

(1) 형사 제재

- 행정형벌(징역, 벌금)

(2) 질서 제재

- 행정질서벌(과태료)

(3) 금전적 제재

- 과징금(이익 박탈 및 제재)

3. 기타 수단

- 공표 등 비금전적 간접 제재 및 영업 정지와 같은 직접적 제재 처분.

V. 결론

- 행정상 실효성 확보수단은 행정법상의 의무 이행을 강제하고 행정목적을 달성하는 데 필수적이다. 대집행, 직접강제와 같은 전통적 수단은 직접적 강제력을 가지나 한계가 명확하여, 이행강제금, 과징금과 같은 새로운 금전적 · 간접적 수단이 중요하게 부각되었다. 이러한 수단들은 국민의 권리 · 의무에 직접적인 영향을 미치므로, 반드시 법률유보의 원칙과 비례의 원칙을 준수하여 행사되어야 하며, 국민은 위법한 행정처분에 대하여 행정쟁송을 통해 권리 구제를 받을 수 있다.